

1500490-65.2021.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500490-65.2021.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500490-65.2021.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TALLISSON VEIGA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. TALLISSON VEIGA DOS SANTOS, qualificado nos autos a fls. 24, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, no artigo

329, parágrafo 2º c.c. artigo 129, caput, do Código Penal, no artigo 330 do Código Penal e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, porque no dia 13 de junho de 2021, por volta das 22h30min, na Rua 42 nº 1, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e Comarca, conluiado e mediante unidade de desígnios com o adolescente E.S.R., teria trazido consigo, para fins de tráfico, oitenta e seis eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto total de 22,620 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, assim como nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, ao praticar aludido crime com o adolescente, teria ao menos facilitado a corrupção deste, que à época contava com quatorze anos de idade. Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, teria o Acusado desobedecido a ordem legal emanada de funcionário público e se oposto à execução de ato legal, mediante violência contra o policial militar J.B.L.M., funcionário competente para sua execução.

Narra a denúncia que “policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado e o adolescente ocupando uma motocicleta sem placas. Diante do que avistaram, os agentes públicos citados emitiram ordem de parada, não sendo, contudo, atendidos, uma vez que TALLISSON e o adolescente continuaram o trajeto, fugindo da Polícia, desobedecendo, portanto, a ordem legal de funcionário público.

Após o denunciado e o menor serem acompanhados pelos policiais, TALLISSON, no cruzamento da Rua 42 com a Avenida 31, perdeu o controle do veículo, caindo ao solo juntamente com o adolescente, momento em que buscaram se evadir a pé.

Um dos policiais logrou êxito em deter o denunciado, ao passo que o outro agente alcançou o menor.

Após luta corporal do policial J.B.L.M. com TALLISSON, uma vez que este, usando de violência, resistiu à abordagem, causando escoriações em membros superiores e no ombro esquerdo do agente mencionado (ficha clínica de fl. 116), o denunciado fora algemado, sendo com ele encontradas as drogas acima descritas, as quais estavam no interior de uma sacola que se encontrava por dentro de sua blusa, juntamente com um aparelho celular.

Na posse do adolescente foi encontrada, mais especificamente no bolso de sua calça, a quantia de cento e dezessete reais e setenta centavos em notas diversas, além de um aparelho celular.”.

A denúncia de fls. 136/139 foi recebida em 13 de julho de 2021 (fls. 141/142). O Réu foi citado a fls. 156, apresentando defesa preliminar em fls. 176/186, rejeitada a fls. 199/201. Na instrução da causa foi colhida prova oral (fls. 263/283) e, ao final, o Réu foi interrogado (cf. fls. 325).

Em memoriais, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação (fls. 323/324).

A douta Defesa, por seu turno, a fls. 326/337 sustentou que o crime do artigo 244-B da Lei 8.069/90 seria formal e não teria sido praticado, ao passo que os delitos de desobediência, resistente e lesão corporal não existiram. Quanto ao tráfico, alega que não existe prova apta a impor o decreto condenatório, motivo por que a ação é improcedente. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou o reconhecimento da primariedade e bons antecedentes do Réu, fixando regime de pena em regime aberto, com substituição da pena corporal por restritiva de direito.

Eis o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Está a materialidade delitiva comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/07, boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação provisória de substância entorpecente de fls.

14/16, comprovante de depósito de fls. 121, no laudo de exame químico toxicológico (fls. 151/153), laudo pericial de exame de lesão corporal (fls. 248/249) e pela prova oral colhida durante a persecução penal.

Certa a autoria delitiva contra o Réu, que na fase inquisitorial optou pelo silêncio (cf. fls. 06), ao passo que em Juízo negou o teor da denúncia, asseverando que pilotava a motocicleta na data dos fatos quando recebeu ordem de parada dada pelos policiais. Como era não tinha placa e documentação, temendo perdê-la, já que emprestada, empreendeu fuga, levando consigo o adolescente, até que vieram a cair e, com isso, foram agredidos pelos policiais, que os colocou na viatura, não mostrando a droga. Ressalta que não tinha entorpecente, que sequer faz uso, somente sendo mostrado posteriormente, não sabendo, no momento em que preso, o motivo disso. Por fim, disse que a motocicleta era emprestada por “um cara” para “um amigo” e que na época trabalhou por cinco meses terceirizado na Usina Guaíra (fls. 325).

De início deve ser destacado que, como se sabe, o direito ao silêncio é cláusula constitucionalmente assegurada, mas não é crível se acreditar que aquele que tenha sido injustamente preso pela prática inclusive de um crime assemelhado ao hediondo tivesse a frieza de manter-se calado para somente em Juízo informar a prisão equivocada, demonstrando que o Réu nada tinha a indicar em sua defesa no momento de sua prisão, cabendo salientar brilhante excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, pois ele “assumiu comprometedor, ainda que legalmente tolerada, postura silente, quando é certo que aquele que se vê injustamente acusado, trata, logo, de anunciar a injustiça da acusação, se convidado a falar sobre ela” (TJSP, Ap. 990.09.059887-5, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 04.08.2009).

Sua versão não se sustenta.

O policial militar Matheus, em fls. 263/268, declarou que estavam em patrulhamento durante a noite quando avistaram o Réu com uma motocicleta sem placas e a partir daí começou o acompanhamento, tendo ele empregado fuga por diversas ruas do bairro e, na Vila Aparecida, próximo da Rua 42, os ocupantes do veículo perderam o controle, conseguindo abordar o Acusado, tendo o menor de idade fugido, mas detido pelo depoente, ao passo que o policial Jordson abordou o Réu, que pilotava a motocicleta. Populares, então, começaram a apedrejar a guarnição, de forma que foram obrigados a colocar o Réu na viatura e deslocar-se até a base, local seguro para fazer busca pessoal, quando, então, foi localizado na jaqueta do Acusado um pacote contendo entorpecentes. Declarou, ainda, que quando chegou com o adolescente que tinha interceptado presenciou o Réu em luta corporal, obrigando que o algemasse e que com o adolescente foi encontrado dinheiro. Ademais, disse que não conhecia o Réu, mas sim o adolescente, porque “a família dele já deu bastante trabalho no tráfico, já é conhecido ali e já se comentava do menor”. Por fim, nem o Acusado, tampouco o adolescente, estavam sob o efeito de droga.

Em linhas gerais, esse foi o teor do depoimento do policial militar Jordson, que ainda detalhou que a motocicleta passou por eles sem placas e como era de conhecimento que o motorista costumava se evadir dos policiais militares, havendo a informação de que ela era utilizada para transportar drogas, deram sinais sonoros e luminosos para que parasse, mas houve fuga por diversos quarteirões. Disse também que o Réu resistiu a sua abordagem, mas apesar de ter recebido socos, a lesão foi causada por pedrada de populares, assim como que havia informação de que o Réu dirigia a motocicleta, a qual serviria para abastecer pontos de drogas (cf. fls. 268/275).

Nem se olvide pelo fato de a acusação se embasar somente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, motivo porque não podem ser

descartados, notadamente porque o Réu não ofertou qualquer resistência ao depoimento deles, nem mesmo os contraditando.

A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, "Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram" (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

Digno de nota que a alegação defensiva de que os policiais teriam prestado depoimento idêntico na delegacia não é impeditivo para a condenação. De pronto, porque a semelhança daqueles depoimentos não é nem de longe indicativo de que teriam mentido, mas que, tendo atendendo a ocorrência em conjunto e prestado declarações logo na sequência, natural que falassem no mesmo sentido, não podendo se ignorar, de qualquer forma, que inexistiu indicativo de prejuízo ao Acusado, sendo certo que além de inexistir irregularidade no inquisitorial, ainda que assim não fosse ela não contaminaria a ação penal porque se trata de mera entrega de peças de convencimento para o titular da ação penal. Nesse sentido, a lição clássica da doutrina de Ada Pellegrini Grinover, "deve se salientar que, seja o prejuízo evidente ou não, ele deve existir para que a nulidade seja decretada. E nos casos em que ficar evidenciada a inexistência de prejuízo não se cogita de nulidade, mesmo em se tratando de nulidade absoluta" (Ada Pellegrini Grinover et alii, As nulidades no processo penal, 10ª ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais: 2007, pág. 31).

Some-se a isso que, em Juízo, os policiais prestaram declarações semelhantes, corroborando aquilo que declararam em solo policial.

As testemunhas de defesa Anderson (fls. 276/278), Reginaldo (fls. 279/282) e Samuel (fls. 282/283), não presenciaram os fatos, relatando que o Réu trabalha e possui bons predicados.

Pois bem.

Em relação ao tráfico de entorpecentes, a conduta do Acusado indica, pois, que no dia, horário e local apontados na denúncia, trazia consigo considerável quantidade de substância entorpecente para fins de traficância, envolvendo, ainda, um adolescente na criminalidade. A isso se chega com a prova coligida aos autos, notadamente a quantidade de cocaína apreendida, bem como a forma como estava o narcótico guardado, além do fato de que o Réu empreendeu fuga ao perceber que seria abordado, sendo que de todo inacreditável que o Réu, que segundo disse teria pegado a motocicleta emprestada, não saberia informar quem lhe forneceu o veículo, uma vez a lacunosa alegação de que ela era "um cara" que emprestou para "um amigo". Ademais, apesar de não ser conhecido dos meios policiais, o depoimento dos militares em Juízo dá conta de que ele era conhecido por pilotar aquela motocicleta a qual havia informações que estava abastecendo pontos de venda de entorpecentes. Não bastasse, o Réu não estava sob efeito de drogas e negou que consumisse entorpecente.

Tais condutas apontam que o Réu iria utilizar o entorpecente apreendido consigo para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006.

Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória. Oportuno salientar que não havia necessidade de o entorpecente estar junto ao corpo do Réu e "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Forçoso se reconhecer, outrossim, que o Acusado, em sua prática nefasta, envolveu o adolescente Felipe (cf. fls. 05). Assim, perfeitamente caracterizada a causa de aumento de pena tipificada no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 que, diante do princípio da especialidade, se sobrepõe ao tipo penal do artigo 244-B da Lei 8.069/90. Nesse panorama: "TRÁFICO. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra dos policiais e confissão parcial do réu. CORRUPÇÃO DE MENORES. Afastamento do delito previsto no art. 244-B do ECA, com reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, em observância ao princípio da especialidade. Condenação mantida e pena reduzida. Apelo parcialmente provido" (TJSP, Ap. 1500490-24.2021.8.26.0062, 1ª C.D.Crim., Rel. Des. Diniz Fernando, j. 12.07.2022).

Ressalto que aquela é a capitulação correta, não como constou da denúncia, ou seja, prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e também violação ao tipo do artigo 244-B da Lei 8.069/90. Destaco que não houve comprovação de fato novo durante a instrução que fizesse a alterar o entendimento quanto à tipificação do delito, o que ensejaria aplicação do artigo 384 do Código de Processo Penal. Dessa maneira, cabe utilização, ao caso em julgamento, da emendatio libelli, prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, aquele pelo qual autoriza que o "O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave". Em outras palavras: narra mihi factum dabo tibi jus!

É que a denúncia descreveu corretamente o fato criminoso, qual seja, no que aqui importa, que o Réu, juntamente com o adolescente, praticavam o tráfico de drogas, de modo que, com a devida vênia, pouco importa, para fins defensivos e consequente apreciação do magistrado, a capitulação fornecida pelo órgão ministerial em sua exordial. Nesse sentido, "se a peça acusatória descrever o fato criminoso perfeitamente, mesmo que tenha havido uma errada classificação da infração, não será obstáculo a que se profira sentença condenatória. Afinal de contas, o réu não se defende da capitulação do fato, mas sim deste. Assim, uma errada classificação da infração não pode constituir obstáculo à prolação de eventual sentença condenatória" (Fernando da Costa Tourinho Filho, Manual de Processo Penal, 9ª ed., São Paulo, Ed. Saraiva: 2007, pág. 753).

De outra forma, em relação ao crime de resistência, ficou devidamente demonstrado que o Acusado, depois de fugir dos policiais, veio a resistir ao legítimo ato administrativo que resultaria em sua abordagem e, não bastante, agiu com violência física contra J.B.L.M., policial no exercício de suas funções. Dessa forma, sua conduta encontra tipificação exata no artigo 329 do Código Penal. Não se pode falar em atipicidade destas condutas porque o Réu agiu com o dolo de ingressar em residência alheia e ainda de resistir à prisão, o que é suficiente para a configuração dos delitos.

Muito embora não se negue que as disposições do crime em análise se aplicam sem prejuízo à pena correspondente à violência (artigo 329, parágrafo 2º, do Código

Penal), os depoimentos dos policiais, mormente da vítima, não deixaram claro se a lesão identificada no laudo pericial de fls. 248/249 foi provocada pelo ato do Réu ou da população, uma vez que foi o policial atingido por pedras, de forma que, com respeito ao princípio in dubio pro reo, inviável reconhecer a pena da violência.

Por outro lado, também comprovada a prática do crime do artigo 330 do Código Penal porque o Réu ignorou ordem dos policiais para parada e empreendeu fuga, não sendo alcançado sem antes se deslocar por vários quarteirões. Nesse diapasão, "No crime de desobediência a questão do subjetivismo da ordem recebida não tem relevância. Ou a ordem é legal, como se presume, na maioria dos casos, ou não o é. Em o sendo, não cabe a quem a recebe discutir-lhe o acerto" (TACrimSP- AC - Rel. Prestes Barra - Juricrim-Franceschini 1/626).

De fato, a desobediência se consumou no momento que o Acusado se opôs à ordem legal de parar o veículo, dada por policiais militares devidamente em viatura, inclusive com sinais luminosos e sonoros. Nesse sentido, "Como se conhece do Direito Administrativo, os atos administrativos apresentam, como atributos, além da presunção de legitimidade e da imperatividade, a denominada auto-executoriedade, que autoriza a própria Administração Pública a forçar o administrado recalcitrante a ele submeter-se. Não tendo havido qualquer abuso, excesso ou desvio de poder da autoridade policial, mas decisão fundada em lei, com vistas ao interesse público, o descumprimento voluntário pelo agente caracteriza o delito de desobediência" (TACrimSP - AC - Rel. Nélon Schiesari - JUTACRIM-SP 77/413).

Sendo assim, a conduta do Acusado o indica como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, no artigo 329, caput, do Código Penal e no artigo 330 do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos e passo a aplicar a pena.

Para o crime tipificado no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, tem-se que o Réu não ostenta antecedentes criminais certificados nos autos que possam ser considerados para exasperação da pena-base (cf. fls. 320/321). Contudo, apreciando os parâmetros legais ditados pelo artigo 59 do Código Penal, ressalto que fora apreendida considerável quantidade de droga para os padrões desta cidade, de modo que a conduta do Réu deve receber uma reprimenda estatal mais vigorosa, posto de maior perniciiosidade e demonstrar periculosidade exacerbada, razão pela qual majoro a pena-base em 1/6 (um sexto) e a fixo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor, à míngua da comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa do Réu, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, reduzindo sua pena ao patamar mínimo: 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

À derradeira, em vista da incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, majoro sua pena em 1/6, à míngua de critérios que indicassem possibilidade de se aumentar a pena acima da fração mínima, e a fixo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu piso legal.

O Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que apesar de sustentar ocupação lícita, a espécie e quantidade de droga apreendida, demonstram que se dedica, exclusivamente, à atividade criminosa do comércio clandestino de drogas. Dessa maneira, torno aquela pena definitiva, ante a inexistência de demais causas legais modificadoras.

Sobre o tema, aliás: "Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'. Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder. Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução" (TJSP, Ap. 0003548-97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado a hediondo, é o inicial fechado. Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência do requisito subjetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Ressalto, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um "pequeno" traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabilizam a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada ao crime hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: "Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações.

Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012).

E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, com redação dada pela Lei 11.719, de 20.06.2008, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele apreendida motocicleta inegavelmente vinculada ao crime, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda do veículo apreendido com o Réu, que deverá ser encaminhado em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

No tocante ao crime do artigo 329, caput, do Código Penal, mantenho a pena no piso porque não existem circunstâncias que permitissem sua alteração nesta fase, tendo o Réu agido com dolo normal da conduta, de modo que a estipulo em 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto.



Na segunda fase da dosimetria, muito embora menor de vinte e um anos de idade, a pena, fixada no piso, não pode ser reduzida ao patamar inferior. Esta orientação levou o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, a editar a Súmula nº 231: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, porque não se comprovaram danos.

Por fim, no tocante ao crime previsto no artigo 330 do Código Penal, fixo sua pena em 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, uma vez inexistentes fundamentos para majorá-la, bem como pagamento de 10 (dez) dias-multa, em seu valor mínimo.

Pela imposição da pena no patamar mínimo, inviável sua redução, na segunda fase, diante da menoridade relativa, nos termos acima expostos.

O Acusado praticou três crimes com três resultados diversos, motivo ao qual incidem as regras do concurso material. Sendo assim, promovo a soma das penas aplicadas, pela incidência do artigo 69, caput, do Código Penal, atingindo o montante de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no menor valor, bem como em 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, este em regime aberto.

Pela escalada de crimes e somatória das penas, inviável a concessão de sursis ou mesmo a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

III. Isso posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com o mister de CONDENAR o Réu TALLISSON VEIGA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, no artigo 329, caput, do Código Penal e no artigo 330 do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma, à pena 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no menor valor, bem como em 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, vedadas a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Tendo em vista que o Réu aguardou seu julgamento em liberdade e não ter surgido fato novo deste então, não se mostra necessária a decretação de sua prisão cautelar, podendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

São devidas custas na forma da lei, delas ficando isento por ser o Réu beneficiário da Justiça Gratuita, pedido de fls. 185 que ora defiro, uma vez presentes os requisitos legais.

P.R.I.C.

Guaíra, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA